

1515353-69.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76

- Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico

ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato

da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515353-69.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515353-69.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2170486/2021 - 05º D.P. ACLIMACAO, 18676991 - 05º D.P. ACLIMACAO, 1411/2021 - 05º D.P. ACLIMACAO, AC1942-1/2021 - 05º D.P.

ACLIMACAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS VINICIUS NAVAS EVANGELISTA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 853/21

VISTOS.

CARLOS ALBERTO DE JESUS ALVES, LUCAS VINÍCIUS NAVAS EVANGELISTA e PLÍNIO CESAR FERNANDES GOMES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, porque consta, que no dia 23 de junho de 2.021, por volta de 17h29, à rua dos Lavapés, 20, Cambuci, São Paulo, qualificados às fls. 06, 07 e 48, previamente

ajustados e com unidade de propósitos, transportavam, para consumo de terceiros, cerca de 8.490,6g de Cannabis sativa L, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida à fls. 108.

Foram apresentadas defesas preliminares à fls. 154/155.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação, e os réus foram interrogados.

Em Debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa dos réus CARLOS e LUCAS, a fls. 177/188, requereu a absolvição dos réus pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pela pena no mínimo; regime mais brando e reconhecimento do tráfico privilegiado.

Igualmente, a defesa do acusado PLÍNIO, em memoriais a fls. 214/220, também pediu a absolvição por ausência de provas suficientes para condenação, reconhecimento da minorante, com pena no mínimo e regime mais brando.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, dando conta dos 15 tijolos de maconha, localizados e apreendidos em poder dos réus.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 166/168, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para tetrahydrocannabinol.

A autoria também é incontestada.

De fato, os argumentos das Dutas Defesas não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra eles derivadas, em especial, pelas testemunhas inquiridas e declarações dos próprios increpados que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Na fase inquisitiva, o réu LUCAS declarou que estava no veículo conduzido por Carlos Alberto, juntamente com Plínio e Ester. Sabia que o veículo estava carregando drogas, mas as drogas não eram dele e, pelo que sabe, Ester não sabia sobre a droga. Quando os policiais chegaram, Carlos tentou fugir com o veículo e o jogou na direção dos policiais, mas os policiais conseguiram alcançá-los. Antes de serem abordados, Plínio conseguiu se evadir. Não sabe o endereço correto de Plínio, mas ele reside na região de Guarulhos.

Em juízo, alterou sua versão sobre os fatos, dizendo que eu encontrei Plínio na Bela Vista, e a gente ia chamar umas meninas. Encontramos Ester, que chamou o Carlos. Ele chegou de carro sozinho, paramos para abastecer, quando desceu um policial em um carro disfarçado dando tiros. Eu saí do carro e me deitei no chão, por isso não vi se a droga saiu do carro os dos policiais. O réu Plínio estava dentro do carro sim. Não conheço Carlos, conhecia Ester do Facebook. Tenho 20 anos de idade e já tive passagem pela Fundação Casa por tráfico de drogas.

O réu CARLOS declarou na fase inquisitiva que conduzia seu veículo juntamente com Lucas e tendo como passageiros Plínio e Ester. Sabia que o veículo estava carregado com drogas, mas não sabe se Ester e Plínio sabiam. Quando foi abordado pelos policiais, tentou se evadir e quase atropelou os policiais, mas foi detido logo depois, quando os policiais deram tiros nos pneus do veículo e ele teve que parar. Quando os policiais chegaram, Plínio conseguiu se evadir. Afirmou que a droga não era dele e não sabe de quem era.

Em juízo, assim como seu comparsa, mudou sua versão, declarando que tudo começou eu estava indo na 25 de março, onde trabalho como puxador e representante de lojas. Eu conheci essa menina Ester, ofereci roupas para ela, eu já tinha ganhado 300 reais de vendas. Ela disse que não queria, trocamos telefone e disse que fazia também trabalho de Uber. No dia dos fatos, ela me ligou e pediu para eu fazer uma viagem para ela. Eu fui até onde ela estava, peguei ela, depois pegamos o réu Plínio, e depois o Lucas. Eles não estavam juntos. Eu peguei um, depois peguei o outro. Eles se conheciam, eu não conhecia nenhum deles. Parei do lado do posto de gasolina, Plínio desceu e foi para o outro lado do posto. Nisso, vieram dois homens

disfarçados da civil, dando tiro. Eu me assustei, tentei dar a ré, mas eles atiraram no pneu. Eu parei o carro, e não sabia das drogas. Apareceu uma caixa lá, com eles. Quando os policiais chegaram, a menina e o Lucas ficaram dentro do carro e eu saí correndo. Já fui preso antes em um assalto. Eu não confessei nada na delegacia, eles me bateram, soco na cara.

Por fim, o réu PLÍNIO, ouvido em Juízo, declarou que eu fui reconhecido por foto. Os policiais não me viram. Não participei desses fatos. Conheço o réu Lucas da vizinhança. Conheci a menor no Facebook, mas não somos amigos. Tenho 21 anos de idade e nunca fui preso antes. Nada tenho contra o réu Lucas nem contra a menina Ester. Não sei por que eles disseram que me reconheceram. Eu estive com Lucas nesse dia, mas depois fui para casa. Estive com ele até por volta das 15:00 horas. Eu vi o Carlos, e Lucas entrou no carro. Não sei se a menor estava também. Eu não entrei no carro, eu fui para casa.

Ocorre, porém, que, enquanto as confissões inquisitivas dos réus Lucas e Carlos vieram embasadas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, suas negações judiciais, acompanhadas das negativas de Plínio, restaram isoladas e em absoluto não convenceram.

As contradições existentes nas versões judiciais dos acusados, fragilizam sobremaneira a possibilidade de serem dadas quaisquer credibilidades a elas. Veja que enquanto Lucas afirma que ele, Ester e Plínio estavam juntos quando chamaram o réu Carlos, este, contrariando a versão do seu comparsa afirmou que na ocasião, primeiro pegou Ester, depois Plínio e por último o acusado Lucas, negando que estivessem juntos. Por fim, Lucas contradizendo ambos, afirmou que sequer chegou a entrar no carro.

Desta forma, não se pode crer que os acusados estivessem por acaso juntos, quando fossem do nada, presos pelos policiais, em poder de grande quantidade de drogas, acusados da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivessem efetivamente participação no crime em voga. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer.

Não há como acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar os réus da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-los condenados.

Os argumentos da combativa defesa, quanto à desobediência do artigo 226 Código de Processo Penal, por ocasião do reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, em nada abalam o caminho condenatório.

Neste sentido, diz a jurisprudência acerca do reconhecimento isolado: “Não anula o ato a circunstância de a pessoa que se pretende reconhecer não ser colocada junto a outras. Esse detalhe, como dispõe a lei, deve ser observado “quando possível”. Trata-se de uma recomendação, não de uma exigência” (RT 711/331).

Dessa forma, não se tem nos autos, a despeito dos argumentos da Douta Defesa, um indício sequer que pudesse evidenciar que toda a prova acusatória tivesse sido produzida com a finalidade única de prejudicar os réus ou mesmo acusá-los falsamente.

O montante de drogas apreendidas em poder dos réus não deixa dúvidas de que servia para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio. Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, as atitudes suspeitas dos réus, a quantidade de drogas encontradas, somado ao relato firme e seguro por parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância.

Tanto que os policiais civis responsáveis pela prisão dos réus, José Wilson Ferreira Lima e Alex Junior Amarilho do Nascimento, ouvidos em Juízo, relataram em uma só voz, de forma firme e segura que estávamos nessa operação, nível Estadual, e tivemos informações de que esse veículo fazia transporte de drogas. Com a informação passada, ficamos em campana na rua informada, quando vimos o veículo passar, e parar logo a frente. O indivíduo que estava no banco traseiro conseguiu fugir. O condutor era o réu Carlos, que tentou jogar o veículo contra nós, que efetuamos um disparo. Ele ainda dirigiu de ré, mas bateu no guard rail. A menor foi detida no local, assim como o réu Lucas. O réu Carlos tentou se esconder atrás de

uma mureta, mas foi detido. No porta-malas do carro foram encontrados os entorpecentes e na delegacia eles confessaram que realmente transportavam as drogas para Favela Heliópolis, e que receberiam 500 reais, mas não sabiam para quem iam entregar. Eles informaram que o terceiro indivíduo que fugiu era o Plínio. Com a identificação dele, ele foi reconhecido fotograficamente pelos demais. Fomos até a residência dele, onde fomos atendidos pela tia de Plínio que informou que não sabia onde ele estava. Reconheço os réus Carlos e Lucas, não tivemos contato com o réu Plínio.

Os policiais civis narraram com segurança e precisão como se deu a prisão dos acusados, relatando todos os detalhes, desde a chegada ao local, em razão de diligências investigativas em relação ao veículo apontado como transporte de drogas, a campana, ordem de parada, a tentativa de fuga dos réus, suas abordagens, o momento em que Plínio conseguiu se evadir, o encontro das drogas no porta-malas do veículo e as confissões de Lucas e Carlos, até final detenção e prisão. Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito, já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido, já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiância" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Em que pesem, pois, os argumentos da defesa, alegando em síntese que tudo não passou de uma armação para incriminar os réus e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Neste contexto, em vista da grande quantidade de drogas encontradas em poder dos réus, a forma como estavam embaladas, de forma individualizada, prontas para venda, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia, pudesse vir a inocentar os acusados da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheram os réus um dos núcleos do tipo denunciado, sendo, pois, impossível a absolvição. Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não terem os agentes sido surpreendidos no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de

mercancia – Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canelas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie. Os réus LUCAS e PLÍNIO são primários e não ostentam antecedentes criminais. Assim, fixo a pena base de ambos no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Já o réu CARLOS é reincidente num roubo, conforme certidão de fls. 52, assim, aumento sua pena em 1/6, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em relação aos réus LUCAS e PLÍNIO, na hipótese dos autos, forçoso se faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos. E isso porque os acusados primários, sem qualquer antecedentes, são jovens e não há um indício sequer a demonstrar que façam parte de alguma organização criminosa.

Assim, considerando-se a quantidade de drogas, reduzo a pena base de ambos em 1/6, perfazendo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em relação ao réu CARLOS, não há que se falar em aplicação da redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que o condenado é reincidente, não possuindo assim, os requisitos subjetivos necessários ao recebimento de tal benefício.

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida – 13 (treze) pedras de crack – justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3” (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012). Pelo mesmo motivo, incogitável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxico, tendo em vista circunstância judicial desfavorável atinente à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (TJESP, Apelação Criminal nº 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO; STF, RHC 94.806/PR; STJ, HC 105.216/SP e 141.921/SP), porquanto o expressivo (e variado) “carregamento” denota estreita vinculação do réu com organização destinada ao tráfico.

O valor do dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar LUCAS VINÍCIUS NAVES EVANGELISTA e PLÍNIO CESAR FERNANDES GOMES DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 33, § 4º, da Lei nº11.343/06, a cumprirem, em regime inicialmente semiaberto a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, como incurso nas penas do artigo 33, § 4º, da Lei nº11.343/06, bem como para condenar CARLOS ALBERTO DE JESUS ALVES, como incurso nas penas do artigo 33, da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente fechado a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Os condenados LUCAS e PLÍNIO iniciarão o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, pois, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime tido como hediondo, daqueles cuja gravidade não permite o início do cumprimento da pena em regime aberto.

Nem mesmo a atual decisão do STJ é capaz de ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que a quantidade de drogas apreendidas em poder dos réus não autoriza o reconhecimento de regime mais brando. Tanto é assim que analisando temas semelhantes, o STF já firmou entendimento no sentido de ser plenamente possível o reconhecimento da minorante prevista na Lei de Drogas, em conjunto com o cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, sem que haja qualquer vinculação

ou obrigatoriedade de ser reconhecido o regime aberto.

Há que se consignar que cada caso concreto possui fatos diferentes, que afastam a obrigatoriedade e a rigidez imposta pelo STJ, de maneira que a aplicação e o reconhecimento da minorante, bem como o regime inicial da pena devem ser analisados de acordo com cada situação específica imposta e apresentada em cada processo. No sentido, vale trazer a colação o seguinte julgado: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO ESCOLHIDA. REPRIMENDA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. NOCIVIDADE DA DROGA QUE APONTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. Razão não assiste ao agravante. Consoante consignado na decisão agravada, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 413.085/SC, não reflete flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, já que alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vide: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO ESCOLHIDA. REPRIMENDA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. NOCIVIDADE DA DROGA QUE APONTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. Esta Corte vem decidindo que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Deve ser mantida a fração redutora de 1/3, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão recorrido aponta a necessidade de uma maior repressão do delito, ante a sua gravidade concreta, evidenciada esta última pela quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (crack). Ademais, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem implica, sem dúvida, revolver o acervo fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. - No caso, inexiste coação ilegal a ser sanada, pois, embora o paciente seja primário e a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão comporte, em princípio, o regime inicial aberto, o regime intermediário foi fixado com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada nocividade da droga apreendida (crack), elemento que, inclusive, justificou a escolha da fração redutora de 1/3 pelo tráfico privilegiado. Inteligência dos art. 33, § 3º, do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - No que tange à possibilidade de substituição da pena - Esta Corte vem decidindo que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração

reduzidora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Deve ser mantida a fração redutora de 1/3, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão recorrido aponta a necessidade de uma maior repressão do delito, ante a sua gravidade concreta, evidenciada esta última pela quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (crack). Ademais, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem implica, sem dúvida, revolver o acervo fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. - No caso, inexistente coação ilegal a ser sanada, pois, embora o paciente seja primário e a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão comporte, em princípio, o regime inicial aberto, o regime intermediário foi fixado com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada nocividade da droga apreendida (crack), elemento que, inclusive, justificou a escolha da fração redutora de 1/3 pelo tráfico privilegiado. Inteligência dos art. 33, § 3º, do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal passou a admitir tal possibilidade, nos termos do art. 44 do Código Penal, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que posteriormente teve sua execução suspensa pelo Senado Federal, por meio da Resolução n. 5/2012. - Na espécie, embora adimplido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP, a nocividade do entorpecente apreendido (crack) não recomenda a substituição, nos termos do inciso III do art. 44 do CP. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido" (fls. 428/429 e-STJ).

De outra banda, o regime semiaberto se justifica, porque a despeito de se tratar de crime de tráfico, assemelhado aos crimes hediondos, não há indícios de que se tratam de grandes traficantes.

O condenado CARLOS iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, pois, além da reincidência, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime tido como hediondo e o artigo 2º, §1º da Lei 8072/90 prevê expressamente, que crimes dessa natureza, terão suas penas cumpridas inicialmente em regime fechado. Além do mais, tratando-se de crime equiparado a hediondo, elencado pela Constituição Federal como inafiançável, sendo vedada a liberdade provisória, antes da condenação definitiva, quando prevalece a presunção de inocência, muita mais descabida é a concessão de qualquer regime diverso, com possibilidade de liberdade cautelar àquele que vem a ser condenado, mesmo que em primeiro grau.

Não é possível, contudo, a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovedor deve ser segregado do convívio social.

Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: "Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: "inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos

precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incider tantum).".

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida. Além disso, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício, uma vez que o crime em apreço possui natureza gravíssima, cujas circunstâncias caracterizadas pelo lucro fácil em detrimento da saúde das pessoas de nossa sociedade, e as consequências do delito que levam à desestabilização familiar e social, indicam que a substituição não se mostra suficiente como forma de retribuição estatal. Qualquer outra pena, que não a privativa de liberdade e em regime fechado, mostrar-se-ia por demasiado tênue, como forma de repressão e retribuição.

De forma idêntica, a Resolução nº 05/12, do Senado Federal, também não obsta aquele posicionamento, visto que o artigo 44, "caput", da Lei de Tóxicos permanece íntegro. Trata-se ainda de crime equiparado aos crimes hediondos, não tendo assim, referida Resolução retirado o caráter hediondo do crime, circunstância que levou o legislador constituinte a prever um tratamento mais rigoroso ao tráfico de drogas. Em arremate, os condenados LUCAS e CARLOS responderam a todo o processo presos e assim devem permanecer, pois foram nesta data condenados a crime de extrema gravidade, dos quais não se admite liberdade provisória, ex vi do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06. A sociedade está aterrorizada com o crescente aumento da criminalidade, em especial, da prática de crimes como deste jaez, cujos agentes não se privam em aliciar jovens em nossas comunidades, causando transtornos irreparáveis em todos os cidadãos de bem.

Com efeito, qualquer outra pena, que não a privativa de liberdade, sem direito de recurso em liberdade, mostrar-se-ia por demais tênues, como medida de repressão, retribuição e ressocialização para o caso em apreço.

Assim, em atenção aos motivos e circunstâncias supras, não concedo aos condenados LUCAS e CARLOS o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade.

Deixo, por fim, de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque os condenados não se encontram presos tempo suficiente para obter os benefícios da progressão de pena.

Além disso, não se tem notícias do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento de tal benefício, os quais somente poderão ser melhor analisados no Juízo das Execuções.

Recomendem-se a remoção do condenado LUCAS para estabelecimento adequado ao regime semiaberto, recomendando-se por sua vez, o condenado CARLOS, no estabelecimento prisional que se encontra recolhido.

Já o condenado PLINIO respondeu a todo o processo solto, é primário e compareceu a todos os atos para os quais foi chamado. Desta forma, com relação a ele, concedo o direito de recurso em liberdade.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de janeiro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
(Juíza de Direito)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA